

宪法审查 违宪审查 司法审查

宪法审查是宪法保障制度的最主要方式

宪法监督：中国宪法上类似的指称（上级对下级宪法实施的审查，但不限于此）

一、宪法审查的起源

1. 英国的“波纳姆医生案”

1610年 科克大法官法律思想的体现（其思想没有在英国成为主流）

无照经营的波纳姆医生与医师协会之间的纠纷（行政裁判处罚）

议会主权——英国的体制

2. 马伯里诉麦迪逊案

1803年 马歇尔大法官的“伟大篡权”

判决主旨：

A. 美国宪法上的有限政府原则（议会权力有限，要受法院合

B. 宪法是“高级法”（效力比普通法高）

C. 法院有权宣告违宪的法律无效（通过判例）

该判决奠定了司法权的地位，开司法宪法审查之先河 使美国成为“活宪法”

3. 欧洲宪法法院的起源

议会至上的传统使得法院不能宣告法律无效

必需寻求法院以外的“宪法秩序的维护者”

20世纪初 奥地利的宪法法院 “凯尔森模式”

德国联邦宪法法院

1949年根据波恩《基本法》建立 集中式的宪法审查机关

宪法秩序的维护者 “第四种权力” “实质上的联邦最高法院”

开创了司法宪法审查的欧洲模式，影响深远

利克大法官的判决主旨：

A. 自己不能成为自己案件的法官（自身不能与当事人/案件裁决结果有利害关系）

B. 普通法高于议会的制定法

C. 法院可以宣告议会法律无效

（自发形成的法律是最为合理的）
科克大法官的思想没有在英国成为主流

对日本产生影响，二战后在违宪审查方面与美国高度一致

二、宪法审查的范围

1. 法律、法规等其他法律文件（抽象行为）的合宪性

宪法审查的最重要内容：针对立法权

克服民主的局限性（容易遭到反多数决质疑）——非理性成分，从众，普通人欠缺从政能力，多数人的暴政

立法是多数人意志的体现（保护少数人的利益）← 违宪审查

2. 国家机关及其工作人员行为的合宪性（具体行为）

A. 行政行为

案例：平等权案件 实际上，在中国此类案件亦大量发生 如乙肝就业歧视 侵害就业平等权

B. 议会的决定违宪（重大事项决定权）

案例：向海外派驻维和部队（德国、日本）

C. 法院判决违宪

案例：智障人绝育案件 —— 现在德国如果当事人认为已生效的司法判决侵犯其基本权利，可以去宪法法院起诉。

D. 政府高级官员的言行违宪 政治公众人物言行影响宪法秩序

弹劾总统案：尼克松水门事件 克林顿事件

日本首相参拜靖国神社案 一反对党起诉，违反宪法政教分离原则，高等法院撤销审判

普通人的行为是否构成违宪？中国的“良性违宪”说 尽管违宪但效果是好的，如邓小平南巡 标准

3. 社团违宪

德国的政党违宪案件

1953年“国家社会主义工人党”违宪案件 防卫型民主 宪法对于违反宪法规定的自由民主秩序的社团要进 行防卫，剥夺结社自由

不构成

三、有利于

1956年 德国共产党违宪案件

取缔邪教案件 我国只有全国人大常委会才有权认定邪教

三、宪法审查的模式 即官办社团是政府机构的延伸，如中国法学会、中国作家协会

1. 分散模式

美国、日本

违宪审查权分散于各级法院之中

宪法解释权由法院行使

——前提是要进入到诉讼程序
附带审查——坚守法院的“司法职能” 附属于某一民/刑事诉讼，在某种民/刑事诉讼中提出，作为审判依据的法律条文是否违宪

观念基础：

a. 对议会的不信任（法院是“危险最小的部门”）

b. 宪法至上（高级法）的宪政理念

c. 普通法的传统（所有案件由同一的法院审查）主要存在于英美法国家

2. 集中模式

奥地利、德国、法国

违宪审查权集中于唯一的宪法法院、宪法委员会（法国）

“宪法秩序的维护者”——独立于立法、行政、司法（最高法）

主要程序类型：

- (1) 合宪性问题先决——在普通诉讼案件中发现条文问题，先把案件移交宪法法院，对合宪性问题做出裁判后再审理原诉讼
- (2) 宪法诉愿 如果当事人认为判决侵犯基本权利，可直接向宪法法院提请宪法诉愿
- (3) 抽象审查（联邦政府、州政府、联邦众议院四分之一以上的议员）当事人直接找宪法法院

四、中国的宪法监督制度

1. 宪法依据

《宪法》第62条规定：

“全国人民代表大会监督宪法的实施，撤销或改变全国人大常委会不适当的决定。”

第67条：“全国人大常委会为宪法监督机构”对法律、法规等规范性文件的监督，由全国人大及其常委会行使；十九大提出“加强合宪性审查”

2. 构成：

(1) 全国人民代表大会对宪法实施的监督

最高监督机关，可以监督包括人大常委会在内的所有机关

但实效性存在严重问题——全国人大会期限

(2) 全国人大常委会对宪法实施的监督

《宪法》第67条 常委会对行政法规、地方性法规是否抵触宪法、法律的审查

《立法法》第99条：

A. 国务院、中央军事委员会、最高人民法院、最高人民检察院和各省、自治区、直辖市的

人民代表大会常务委员会可向常委会提出审查要求 只要提出即审查，直接挑战。（Tip: 违反上位法，如果是宪法则涉及合宪性问题，如果违反上位法是全国人大制定则涉及合法性问题）

B. 其他国家机关和社会团体、企业事业组织以及公民认为行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例同宪法或者法律相抵触的，可以向全国人民代表大会常务委员会书面提出进行审查的建议，由常务委员会工作机构进行研究，必要时，送有关的专门委员会进行审查提出意见。——备案审查

C. 有关的专门委员会和常务委员会工作机构可以对报送备案的规范性文件进行主动审查。

2018修宪 成立“宪法和法律委员会”

(3) 全国人大专门委员会对行政法规、地方性法规的监督

《立法法》第100条的规定：

对象：行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例

最高法的司法解释也可以受到合宪性审查

方式：向指定机关提出书面审查意见；召开联合审查会议，要求说明情况、提出书面意见

(4) 地方各级人民代表大会及其常务委员会监督、保障宪法在本地区内的实施

《宪法》第99条：保障宪法、法律、行政法规在本行政区域内的遵守和执行

第104条：县级以上人大及其常委会撤销本机政府不适当的决议和命令，下级人大

上临下，人大监督同级政府

3. 人民法院有限的宪法解释权

“宪法的司法适用解释权”——在审判工作中具体应用的宪法解释权

但不能审查法律、法规的合宪性

2016年6月28日，最高人民法院发布了《人民法院民事裁判文书制作规范》，其一方面明确规定“不得引用宪法作为裁判依据”，而另一方面又规定“但其体现的原则和精神可以在说理部分予以阐述”

五、违宪审查的基准问题

1. 美国的双重审查基准、德国的三重审查标准，均要求对精神自由、表达自由（加强保护）与经济自由的限制采用不同的审查基准

2. 精神自由（分为内在和外在的精神自由）：

1) 事前抑制、过度广泛抑制（使表达活动脱离本意，无法实现原来的效果）

——直接判定违宪

（事前抑制：要经过政府部门事先的审查才能表达，即许可制）

2) 表达内容的规制

——若有明显且即刻的危险，则立法/公权力部门可以对表达的内容进行限制

3) 表达时间、地点、方法的规制

——LRA(限制程度最小之手段) less restrictive alternatives

（比例原则）

——一方面要保护公共利益和公共安全，另一方面要保护言论自由

2. 经济自由：

(1) 如私有财产所有权，契约自由、营业自由、择业自由等，

(2) 也包括国家对国民生存福祉的保障，如失业救济金和养老保险等

(3) 对经济自由的限制包括：

1) 消极目的规制：合理性基准，等同于LRA

——国家不干预就可以实现，若要限制则要运用合理性基准（同精神自由3，限制程度最小之手段——如果能找到一个其他的限制手段，比该手段的限制程度更低，并同样能够实现我的管理的目的，那么该手段就不是限制程度最小手段

2) 积极目的规制：较为宽松的明显原则

——如果手段明显不合理，才可以进行限制，如政府不发放失业救济金等社会福利会影响到其他更为重要或者与之相当的自由，则违宪

